

1500482-34.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... pela apreensão de anotações típicas de contabilidade do tráfico.

Neste sentido:

"APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

1500482-34.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500482-34.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE MOREIRA DO ESPÍRITO SANTO e outros

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

PEDRO HENRIQUE MOREIRA DO ESPÍRITO SANTO, RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES, JHONATAN SILVA LIMA e KAWAN DAVID MORAIS DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo relata a denúncia, no dia 03 de março de 2021, por volta das 14hs, na Rua Hum, nº 01, Mogi das Cruzes/SP, PEDRO HENRIQUE MOREIRA DO ESPÍRITO SANTO, RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES e JHONATAN SILVA LIMA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia, 41 (quarenta e um) invólucros contendo 167,18g de Cannabis Sativa L, 75 (setenta e cinco) invólucros contendo 31,8g de

cocaína e 125 (cento e vinte e cinco) invólucros contendo 94,1g de cocaína na forma de crack, substâncias entorpecentes listadas na Portaria nº 344/1998, SVS/MS, Lista F1 e F2 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil).

Consta, também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local acima mencionados, KAWAN DAVID MORAIS DA SILVA concorreu de qualquer forma para que os acusados PEDRO HENRIQUE MOREIRA DO ESPÍRITO SANTO, RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES e JHONATAN SILVA LIMA trouxessem consigo as drogas acima discriminadas.

Consta, ainda, que, em data indeterminada até o dia 03 de março de 2021, nesta cidade de Mogi das Cruzes/SP, PEDRO HENRIQUE MOREIRA DO ESPÍRITO SANTO, RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES, JHONATAN SILVA LIMA e KAWAN DAVID MORAIS DA SILVA associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o delito de tráfico de drogas.

Recebida a denúncia (fls. 254/256), os réus foram regularmente citados (fls. 310, 312, 320 e 322) e apresentaram respostas escritas à acusação (fls. 288/295, 315/317 e 328).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha arrolada pela defesa e, ao final, foram realizados os interrogatórios dos réus (fls. 418).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação dos acusados, sustentando a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

A i. Defesa do acusado Pedro Henrique Moreira do Espírito Santos apresentou alegações finais às fls. 437/445, oportunidade em que pleiteou a absolvição do réu, alegando a inexistência de prova suficiente nos autos para ensejar a condenação. Subsidiariamente requereu o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a aplicação do concurso formal próprio, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Pela Defesa dos réus Jhonatan Silva Lima e Kawan David Moraes da Silva foram apresentadas alegações finais às fls. 449/461, nas quais se requereu a absolvição dos acusados por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação de delito de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a imposição de pena mínima e de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa do acusado Rafael de Oliveira Lopes apresentou alegações finais às fls. 463/470, oportunidade em que pleiteou a absolvição do acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a imposição de regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É o relatório.
DECIDO.

Prefacialmente, passo a analisar a questão da nulidade dos depoimentos dos policiais civis arguida pela defesa do acusado Pedro Henrique.

O pedido formulado pela defesa não comporta acolhimento.

De fato, os policiais civis utilizaram a mesma conexão para prestar depoimento, circunstância que em nada macula a higidez de tais testemunhos, pois sequer há indícios de que estariam na mesma sala ou que teriam escutado o depoimento do outro.

Basta ver-se tais depoimentos para constatar que não houve a alegada quebra de incomunicabilidade, já que um policial se recordou de mais fatos sobre a ocorrência do que o outro.

Apenas há uma tentativa de desqualificar os seus testemunhos sem o mínimo de elementos com o único intuito de eximir o acusado de tão grave imputação.

Tivesse, de fato, havido qualquer quebra de incomunicabilidade, por certo, os demais defensores também teriam se insurgido contra tal ato, não sendo esse o caso.

Assim, rejeito a alegação preliminar ao mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 18/25, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 30/32, pelo laudo de constatação de fls. 93/102, pelos laudos periciais de fls. 385/391 e 392/395, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 396/404, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos delitos é incontroversa.

O acusado Pedro Henrique Moreira do Espírito Santo confessou em Juízo a prática do tráfico de drogas apenas da cocaína que estava em seu bolso. Disse que os corréus estavam apenas próximos ao local em que estava e desconhece a quem pertencia o dinheiro apreendido. Afirmou não ter praticado a traficância em outras ocasiões no local em que foi detido, posto que utiliza o local apenas como passagem. Disse que cedeu a pedido de desconhecido para iniciar no tráfico e que receberia naquele dia quarenta reais pela traficância. Nega ter jogado uma pochete como dito pelos policiais e, na ocasião dos fatos, havia cerca de sete a oito pessoas no local, porém não vendia a elas as drogas. Desconhece a quem pertencia a pochete, assim como não visualizou ninguém jogando nenhum objeto. Disse nunca ter feito uso de drogas, que conhece os corréus apenas de vista do bairro em que mora, bem como está arrependido de ter praticado o delito.

O acusado Rafael de Oliveira Lopes negou em Juízo a prática do delito a ele imputado. Disse que, como de costume, estava no local em que foi abordado com outras pessoas, ressaltando que em seu poder havia apenas trinta reais. Contou que conhecia os demais corréus apenas de vista. Disse que atualmente está preso pela prática de delito idêntico.

O acusado Jhonatan Silva Lima contou que estava no local em que foi abordado na companhia do corréu Kawan apenas para fumar dois cigarros de "maconha" que trazia consigo, salientando que os corréus Pedro Henrique e Rafael estavam do outro lado. Disse que os policiais realizaram a abordagem de dez pessoas, dispensando outras seis e realizando sua prisão e dos demais corréus. Contou já ter respondido a ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Disse que conhece o acusado Pedro somente de vista do conjunto residencial em que moram.

O acusado Kawan David Moraes da Silva negou em Juízo a prática do tráfico de drogas, afirmando que estava no local apenas para fumar um cigarro na companhia do corréu Jhonatan. Contou que conhece os corréus Rafael e Pedro somente de vista e que já respondeu a delito idêntico. Desconhece o fato de que o acusado Rafael

praticava o tráfico de drogas no local dos fatos. Disse que estava alterado em razão de ingestão de bebida alcóolica e consumo de drogas e que, no momento da abordagem, deitou no chão e não visualizou nada, motivo pelo qual não pode dizer se alguém jogou algum objeto. Afirmou que, no momento da abordagem, estava junto com os demais corréus. Explicou que, na ocasião dos fatos, não comprou drogas do corréu Pedro e não tinha conhecimento de que ele traficava no local.

No caso em tela, as provas produzidas em Juízo permitem de maneira segura concluir pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico em relação aos réus.

O policial civil Antonio Angelo Mota Sardinha contou que, em companhia do policial Marcos Rebert dos Santos, diligenciou com viatura descaracterizada para local com alta incidência de tráfico de drogas. Assim, disse que ficou observando a movimentação existente no local por cerca de cinco minutos, em distância aproximada de quinze a vinte metros, tendo constatado que os acusados Pedro e Rafael estavam em atitude típica de tráfico de drogas. Esclareceu que o acusado Jhonatan estava na companhia dos corréus Pedro e Rafael, enquanto o corréu Kawan exercia a função de "olheiro", de modo que constatada a movimentação de tráfico de drogas, decidiram abordar os réus, sendo que o réu Pedro dispensou uma pochete debaixo de um trailer que continha cocaína, enquanto o corréu Rafael dispensou duas garrafas que continha crack em seu interior. Contou que, em revista pessoal, apreendeu em poder do acusado Pedro certa quantidade de cocaína, em poder do acusado Rafael anotações típicas do tráfico de drogas e com o acusado Jhonatan um maço de cigarro contendo "maconha" a granel. Disse, ainda, que no momento da abordagem também foi dispensado certa quantia em dinheiro, porém não pode dizer qual dos réus teria realizado tal ato. Contou que a conduta do acusado Kawan era a de conversar com Pedro e Rafael e se postar para olhar a rua para visualizar quem vinha ao local. Disse que, no dia dos fatos, conversou com familiares de um dos acusados, não se recordando qual deles. Informou que, no momento da abordagem, havia outras pessoas no local, porém nenhuma delas empreendeu fuga. Contou que os acusados Pedro e Rafael confessaram a prática do tráfico de drogas no momento da abordagem. Disse não se recordar se em poder do acusado Rafael foi encontrado certa quantia em dinheiro.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Marcos Rebert dos Santos. Assim se manifestou:

"A gente foi verificar lá várias denúncias de tráfico de entorpecentes conhecido como "Conjunto Toyama". Realmente lá já é conhecido pela traficância. Eu e o policial Antonio fomos em viatura descaracterizada até o local e entramos no conjunto habitacional. São vários prédios e vários blocos e conseguimos entrar sem ser percebidos, até porque tem um fluxo grande moradores ali. Conseguimos entrar com a viatura e deixa no estacionamento ali, desembarcamos e começamos a observar os quatro indivíduos que estavam em um 'trailer' de lanche que estava fechado no momento. Não sei se funciona. Ali a gente pode ver outras pessoas chegando e fazendo trocas de objetos com eles, no caso Pedro e Rafael. A gente observou que estava o Pedro com uma 'pochete' na mão, uma bolsinha, enquanto Rafael tinha duas garrafinhas plásticas. Lá também estava o Kawan o que aparentava o que a gente chama de 'olheiro' que ficava entre os outros dois indivíduos e verificando movimentações da rua que pudesse atrapalhar a traficância, mais outro indivíduo Jhonatan e a gente não visualizou ele passando nada para ninguém, mas permanecia ali junto aos outros três ali no 'trailer'. A gente decidiu abordar e próximos deles, eles perceberam a aproximação que eram pessoas diferentes do meio, do convívio ali, foi quando percebemos que o Pedro se desvencilhou da 'pochete' que ele trazia na mão, a bolsinha, jogando-a debaixo do 'trailer' que eles estavam. Rafael também dispensou as duas garrafinhas também, embaixo do 'trailer'. Na revista pessoal, eu que fiz, encontrei com Pedro cerca de quinze porções de cocaína e com Rafael anotações aparentemente ao tráfico da movimentação do tráfico. Embaixo do 'trailer' também uma quantia em dinheiro, pouco mais de quatrocentos reais e

notas trocadas. Rafael e Pedro ali mesmo confessaram a traficância, enquanto os outros dois negaram e disseram serem apenas usuários. Com Jhonatan foi encontrado um maço de cigarro e no interior ao invés de cigarros tinha uma porção de 'maconha' a granel. Foi pedido apoio para conduzir os quatro a central de flagrantes. Não vi Jhonatan em conduta de tráfico entregando nada para ninguém, só portava esse maço de cigarro com a maconha. O dinheiro estava debaixo do 'trailer'. Eles estavam todos juntos bem encostado com o 'trailer'. Quando o dinheiro foi encontrado estava junto com as drogas que eles se desvencilharam. Esse 'trailer' tem uma mesa de bilhar, então deve ser uma espécie de bar que vende bebida alcóolica. Fica dentro do condomínio. Que eu tenha reparado só esse estabelecimento mesmo. Kawan como pode se observar parecia espécie de 'olheiro'. Ora ele ficava junto aos outros três indivíduos, aí ele saía dava uma olhada na entrada do prédio, voltava e fazia como se fosse uma segurança. Ele parecia estar alterado. A campana durou por volta de cinco minutos. Acredito que a minha distância dos réus era de dez a quinze metros, mais ou menos isso. Que eu me recorde não havia dinheiro com Pedro, somente entorpecente. A abordagem foi pelos prédios mesmo, tem um fluxo grande de pessoas e até por isso que a gente passou despercebidos. Esse 'trailer' onde eles ficam, fica bem no meio do conjunto habitacional e a gente pela rua, conforme você entra pelo estacionamento, tem acesso aos prédios. A rua é bem próxima, a rua principal, tem a entrada ao interior do conjunto habitacional onde eles ficam ali. Nós fomos até o apartamento do Pedro para buscar o documento de identidade e no momento tinha um irmão menor e não entramos na residência porque tinha um cão que parecia ser bravo e depois apareceu acho que a irmã dele. Expliquei para ela o que tinha acontecido. Nesse local tinha algumas pessoas próximas, aliás várias pessoas, entre moradores, crianças, o fluxo é grande até pelo horário, à tarde, estava sol, o pessoal tem costume de ficar transitando por ali. Foi coisa de cinco minutos de campana, mais ou menos. Não vi ninguém correndo. Próximo deles tinha outras pessoas e com os outros não foi encontrado nada".

Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pelos policiais, no caso concreto.

Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

"Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander)"

Por derradeiro, foi ouvida uma testemunha arrolada pela defesa.

A testemunha Suelen Caroline Moreira do Espírito Santos, irmã do corréu Pedro Henrique, disse ter tomado conhecimento da prisão de seu irmão quando os policiais compareceram em sua residência, motivo pelo qual também se dirigiu para a delegacia de polícia, local em que tomou conhecimento por intermédio dos policiais que seu irmão tinha assumido que traficava doze porções de drogas que estavam no poder

dele, dizendo, ainda, que não havia com ele nenhuma “pochete”. Contou que seu irmão não é usuário de drogas e que sempre trabalhou ajudando financeiramente sua mãe, inclusive trabalha atualmente. Por fim, disse que seu irmão se mostrou bastante arrependido do ocorrido.

O depoimento prestado pela testemunha de defesa não encontra o mínimo de respaldo nas provas existentes nos autos.

Neste ponto, destaco que o depoimento da testemunha deve ser analisado com ressalvas, tendo em vista o vínculo de parentesco com o acusado Pedro Henrique, razão pela qual a sua versão não possui força probatória suficiente para infirmar o quanto já apurado nos autos.

Como se vê, o depoimento da testemunha supramencionada não trouxe elementos aptos a desfazer o panorama fático-probatório totalmente desfavorável ao acusado.

Como dito, as provas produzidas em Juízo são firmes e seguras ao apontar os acusados, como sendo autores do delito de tráfico de drogas.

Inicialmente, é de se destacar que o acusado Jhonatan confessou que os corréus Pedro e Rafael vendiam drogas, quando ouvido na fase policial (fls. 16/17), tendo mudado a sua versão em Juízo sem que tivesse apresentado motivo razoável para ter mudado a versão.

Já o acusado Pedro Henrique confessou que praticava a traficância, embora ressaltando que vendia somente as drogas que foram apreendidas em seu poder.

Não há como se crer que policiais, no exercício regular de suas funções, sem qualquer motivo concreto, fossem prender os acusados e acusá-los falsamente do crime de tráfico.

A situação flagrancial, a natureza, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, as anotações de contabilidade do tráfico de drogas apreendidas, a quantia em dinheiro também apreendida, conforme auto de exibição e apreensão, em local notoriamente conhecido pela alta incidência de tráfico de drogas com várias denúncias de traficância, evidenciam a prática de mercancia ilícita pelos réus.

Ressalto que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, basta a finalidade de guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, para caracterizar o crime em questão.

Destaco que as provas são seguras nesse sentido e ficaram comprovadas não só pelos depoimentos prestados, como também pela variedade e quantidade de drogas apreendidas.

Assim, no caso em tela, fica afastada a tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que os elementos são claros no sentido de que o réu praticava o comércio de drogas.

Além disso, o fato de Jhonatan e Kawan serem usuários de entorpecentes, conforme sustenta a defesa, por si só, não altera o conjunto probatório, já que é notório o fato de que muitos usuários acabam comercializando entorpecentes justamente para manter o vício.

Ficou, outrossim, sobejamente comprovado que os acusados agiam em associação criminosa com a finalidade de comercializar drogas no conjunto habitacional em que residiam, incumbindo a cada um o exercício de uma atividade distinta dentro da organização.

Reputo conveniente traçar os principais contornos do crime imputado na denúncia aos réus, o de associação para o tráfico de drogas.

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”.

Assim, para sua tipificação é necessária a presença dos seguintes elementos:

- a) associação de duas ou mais pessoas;
- b) acordo prévio dos participantes;
- c) vínculo associativo permanente;
- d) finalidade de traficar drogas.

Associação significa união de pessoas, exigindo o tipo o mínimo de duas pessoas. Essa associação deve ter um vínculo permanente, que significa duradouro. E a intenção dos agentes deve ser a de atuarem juntos para a prática dos crimes de tráfico.

Consuma-se com o acordo prévio e duradouro entre os dois ou mais participantes, não se admitindo a tentativa, pois a mera associação já configura o crime consumado.

Irrelevante, outrossim, para a consumação do delito, que haja a apreensão de substância entorpecente ou então a prática efetiva do delito previsto no artigo 33 da mesma lei, desde que fique demonstrado que a associação de pessoas continha um ajuste prévio e duradouro, o que afasta, de conseqüente, a mera reunião ocasional de coautores para a prática de determinado crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Como esclarece Guilherme de Souza Nucci, “a advertência feita no tipo penal (reiteradamente ou não) quer apenas significar que não há necessidade de haver habitualidade, ou seja, não se demanda o cometimento reiterado das figuras típicas descritas nos arts. 33 e 34, bastando a associação com o fim de cometê-los” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 414).

Pois bem.

O acusado Pedro Henrique, em Juízo, confessou que vendia entorpecentes, enquanto Jhonatan, embora tenha negado a autoria em seu interrogatório judicial e dito que apenas conhecia os demais corréus, em Delegacia de Polícia afirmou que os corréus Pedro e Rafael vendiam drogas.

Ainda, os policiais ouvidos em Juízo confirmaram que ficaram observando a movimentação existente, após receberem várias denúncias de tráfico de drogas no local, tendo constatado que os acusados Pedro e Rafael estavam em atitude típica de tráfico de drogas. Esclareceram que o acusado Jhonatan estava na companhia dos corréus Pedro e Rafael, enquanto o corréu Kawan exercia a função de “olheiro”, Disseram que, no momento da abordagem, o réu Pedro dispensou uma pochete debaixo de um trailer que continha cocaína, enquanto o corréu Rafael dispensou duas garrafas que continha crack em seu interior. Contaram que, em revista pessoal, apreenderam em poder do acusado Pedro certa quantidade de cocaína, em poder do acusado Rafael anotações típicas do tráfico de drogas e com o acusado Jhonatan um maço de cigarro contendo “maconha” a granel.

Assim, ficou sobejamente comprovado que os acusados Pedro, Jhonatan e Rafael tinham como função a venda e a guarda dos entorpecentes, enquanto ao acusado Kawan incumbia a vigilância do local, de forma a evidenciar organização para a empreitada

criminosa.

Destaco que as provas são seguras nesse sentido e ficaram comprovadas não só pelos depoimentos prestados pelos policiais, como também pela quantidade de drogas apreendidas e pela apreensão de anotações típicas de contabilidade do tráfico.

Neste sentido:

“APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo correto. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, “in casu”, o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014)”

Deste modo, não houve o mero concurso de agentes, mas sim evidenciadas a estabilidade e a permanência necessárias para a configuração do delito de associação.

Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade a condenação dos acusados pelo delito de tráfico de drogas e de associação para o tráfico é medida de rigor.

Passo, então, à fixação da pena.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, o qual indica todos os parâmetros para a fixação da pena-base, levando-se em conta as circunstâncias do crime, a quantidade, a variedade e em especial a nocividade da droga apreendida (crack) – que possui alto poder lesivo à saúde –, fixo a pena-base aumentada em um sexto, vale dizer, pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No caso vertente, o aumento da pena-base justifica-se à luz da nocividade do entorpecente comercializado pelos acusados, o qual possui alto grau de lesividade e dependência aos seus usuários.

Sobre o tema, colaciono parte do acórdão da lavra do i. Des. Pinheiro Franco:

“O crack (subproduto da cocaína), não se olvide, é estupefaciente altamente viciante e vem causando grande preocupação na sociedade, em razão da proliferação de seu uso. O viciado em crack, na maioria das vezes, acaba deixando a família, perde o emprego e bens, passando a viver nas ruas e enveredando, muitas vezes, para a senda do crime, de modo a sustentar sua severa condição de dependência química. Aquele que traz consigo, com vistas ao fornecimento ao consumo de terceiros, vinte

e oito porções de entorpecente de tal natureza capaz de causar dependência quase imediata -, possui personalidade deturpada e conduta social altamente reprovável, devendo ser punido com mais rigor ainda, em homenagem ao binômio reprovação-prevenção." (Apelação nº 0015447-27.2014.8.26.0361 - 73ª. Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo)

No entanto, com relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, verifico que não há motivos concretos para ensejar a fixação acima do mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, reputo cabível o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa dos corréus Pedro Henrique e Rafael, de forma que reduzo a pena do crime de tráfico de drogas em um sexto, fixando-a no mínimo legal, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo previsto em lei, em observância a Súmula 231, do C. STJ. Entretanto, em relação ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, deixo de reduzir a pena, porquanto já fixada em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Incabível o reconhecimento da circunstância atenuante referente à confissão do corréu Pedro Henrique, uma vez que esta não fora integral e teve nítido cunho exculpatório.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que os réus não preenchem os requisitos exigidos, uma vez que a variedade, a grande quantidade de drogas apreendidas e a associação criminosa na prática do tráfico de drogas, demonstram que possuem ligação com atividades criminosas.

Não há como se crer que os acusados teriam acesso a grande quantidade de drogas, atuando de forma organizada e estruturada, sem que tivessem qualquer tipo de vínculo com organização criminosa. Ademais, o acusado Kawan responde a delito idêntico, indicando o anterior envolvimento na prática de tão nefasto delito.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça "Configurado o crime de associação para o tráfico, fica vedada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por expressa determinação legal" (HC 349.8378/SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, DJ 03/05/2016).

Também já decidiu a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06" (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Incabível, pois, a redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sobre o tema, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador Geraldo Wholers (Apelação nº 0427092-39.2010.8.26.0000 - 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

"O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades

criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais. No âmbito desta Colenda Câmara, registrou o preclaro DES. LUIZ ANTÔNIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que "essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder". A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro - a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida. É assim que se deve considerar a exigência de "não se dedicar às atividades criminosas" (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente... Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)."

Ressalto que o crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico devem ser tidos em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, uma vez que foram praticados mediante diversas condutas, com objetividade jurídica distintas.

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Ressalto que não há qualquer inconstitucionalidade no tipo legal do tráfico, ou mesmo em seu preceito secundário, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece um maior rigor contra os crimes hediondos e aos equiparados a estes.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo, deverão os réus iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena.

Neste ponto, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra o i. Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan (Apelação nº 0014063-92.2015 - 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo):

"O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência

Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Outro regime seria insuficiente para a reprovação de tráfico dessa monta. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios”.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar:

- PEDRO HENRIQUE MOREIRA DO ESPÍRITO SANTO e RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES como incursos no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-OS ao cumprimento de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa;

- JHONATAN SILVA LIMA e KAWAN DAVID MORAIS DA SILVA como incursos no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-OS ao cumprimento de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1283 (um mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa.

Defiro o recurso em liberdade, uma vez que responderam solto e não há elementos a ensejar, nesse momento, a decretação de suas prisões preventivas.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva e mandados de prisão.

Por fim, determino o perdimento da quantia apreendida em favor da União, a destruição dos objetos apreendidos, bem como a incineração dos entorpecentes.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 31 de março de 2022.